

0001700-19.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... com a finalidade de cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, para posterior fornecimento e venda a terceiros.

Assim, pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, na forma mencionada na denúncia.

Por fim, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001700-19.2022.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001700-19.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2044221/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 23047651 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 528/22/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2044221 - DEL.POL.SALTO, 528/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DOS SANTOS PRADO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

FELIPE DOS SANTOS PRADO, qualificado nos autos, e sua companheira Juliana Grazielle de Lima Guimarães foram denunciados, nos autos de nº 1500393-53.2022.8.26.0526, como incurso no artigo 35, caput, e no artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, tudo c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em momento incerto, mas anterior às 23h15min, de 15 de fevereiro de 2022, na Rua Itatiba, nº 488, Jardim Marília I, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, associaram-se a um indivíduo ainda não identificado, para a prática, reiterada ou não, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas). Também

porque, na data de 15 de fevereiro de 2022, por volta de 23h15min, na rua Itatiba, nº 488, Jardim Marília I, nesta cidade e comarca de Salto-SP, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com terceiro indivíduo ainda não identificado, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, adquiriram, tinham em depósito e guardavam, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 350 (trezentas e cinquenta) porções da substância popularmente conhecida como "lança-perfume", com massa bruta de 3,9kg (três quilos e novecentos gramas); 94 (noventa e quatro) porções de "cocaína", com massa bruta de 144,78g (cento e quarenta e quatro gramas e setenta e oito centigramas); 24 (vinte e quatro) porções de "cocaína", com massa bruta de 20,41g (vinte gramas e quarenta e um centigramas); 12 (doze) porções de "maconha", contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), com massa bruta de 30,04g (trinta gramas e quatro centigramas); e 38 (trinta e oito) porções de "cocaína", em sua forma petrificada, popularmente conhecida como "crack", com massa bruta de 25,12g (vinte e cinco gramas e doze centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu Felipe foi notificado (fls. 174/175) e ofertou defesa prévia (fls. 99/101). A denúncia foi oferecida em 17 de março de 2022 (fls. 87/90) e recebida definitivamente em 07 de abril de 2022 (fls. 108/110 e 161/162). O ré foi citado (fls. 229/230).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas pela acusação e 05 testemunhas arroladas pela defesa. Ao final, o réu e a companheira foram interrogados (fls. 244/246).

Determinou-se o desmembramento dos feitos para instauração de incidente de dependência químico-toxicológica no tocante ao réu Felipe (fls. 257-258), sendo gerado o presente feito desmembrado.

O incidente foi processado sob nº 0001701-04.2022.8.26.0526 e o laudo homologado no incidente foi juntado a fls. 271/278 destes autos.

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal e reconhecimento da agravante constante da denúncia, entendendo não ser possível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, pugnou pela imposição de regime fechado, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 291/307). A Defesa, por sua vez, suscitou preliminares e, no mérito, requereu a improcedência da ação, quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, por ausência ou insuficiência probatória, o reconhecimento da atenuante da confissão no tocante ao crime de tráfico de drogas, a redução prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, a detração e o direito de apelar em liberdade (fls. 312/326).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito, e considerando que as preliminares defensivas se baseiam nas ilegalidades atinentes ao ingresso no domicílio e à atuação dos guardas municipais, tudo com enfoque na abordagem inicial recebida pela acusada Juliana, cuja responsabilidade foi apurada nos autos de nº 1500393-53.2022.8.26.0526, permito-me transcrever o que disse a ré naqueles autos.

Em sede policial, Juliana disse que ela e Felipe começaram, juntos, a armazenar drogas na casa. Contou que Felipe recebia a droga de uma pessoa que ela desconhecia, e ganhavam R\$300,00 (trezentos reais) por semana, para ajudar no aluguel no final do mês. Disse que foi até a esquina para procurar Felipe, mas ele não estava lá, e chegaram os guardas, que disseram haver uma denúncia e perguntaram se podiam entrar na casa para verificar se havia alguma coisa irregular, e ela disse que havia lança-perfume e maconha, pois seriam usuários desta última. Contou que lhes mostrou o lança-perfume, o crack e a cocaína, o Felipe chegou e ela assumiu tudo apenas porque se sentiu acuada. Ao final, disse estar arrependida. Em juízo, a ré alterou a versão, e disse que não são verdadeiros os fatos. Contou que foi abordada pelos guardas, eles pediram que ela abrisse a porta de casa, perguntando se tinha algo no bolso. Disse que se recusou inicialmente, mas acabou

autorizando a entrada depois. Dentro da casa, numa caixinha ao lado de sua cama, os guardas encontraram 03 pinos de cocaína, que seriam para uso do Felipe. Disse que os guardas continuaram procurando e encontraram, dentro de uma caixa, embaixo da televisão, uma mochila com drogas, que não eram suas. Alegou que, duas semanas antes, já tinha pego o réu com essa mochila de drogas em casa, abriu a mochila e o questionou, mas ele disse apenas que seria uma forma de conseguir dinheiro. Disse que limpa a casa uma vez por semana, e não havia mais percebido a presença da mochila ali. Afirmou que morava com o réu há três meses, sabia que ele possuía antecedentes criminais por "assalto", mas desconhecia o arrendamento da biqueira no bairro. Disse que já foi usuária de maconha, mas deixou de usar, que estudou, fez faculdade de recursos humanos, curso de qualidade e sempre trabalhou. Afirmou que não faz tratamento de saúde e nem toma remédio algum, e que já passou por psicólogo quando era pequena, porque seu pai agredia sua mãe. Confirmou que leu o que falou na Delegacia antes de assinar, apenas estava um pouco nervosa e confusa. Reafirmou que a droga era apenas de Felipe, mesmo tendo sido encontrada dentro da mochila, em seu quarto. Afirmou que a televisão estava queimada e eles não dormiam naquele quarto, apenas na sala.

No tocante à alegação de ilegalidade da prisão por invasão de domicílio, importante frisar que não se trouxe qualquer elemento aos autos, a comprovar as mencionadas alegações de suposta ameaça sofrida pela acusada Juliana, pessoa diretamente interessada em desmerecer o trabalho feito na seara policial, em detrimento das palavras dos funcionários públicos, que carregam consigo a chancela da Fé Pública, e a veracidade e boa qualidade de seus serviços não podem ser desmerecidas por uma mera alegação desprovida de demais elementos. Imperioso, ainda, consignar que, diferentemente do que alega a Defesa do réu Felipe, a acusada Juliana, quando ouvida em juízo, disse apenas que havia se recusado a autorizar a entrada dos guardas num primeiro momento, mas posteriormente acabou lhes franqueando a entrada. Quanto à efetivação da prisão em flagrante, realizada por guardas municipais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que inexistente tal ilegalidade, já que o artigo 301, do Código de Processo Penal, permite que qualquer pessoa, particular ou servidor público, prenda quem estiver em flagrante delito.

Nesse sentido, cabe trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...]

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 421.954/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. [...] 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). 5. Habeas corpus não

conhecido. (HC 286.546/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2015, DJE 15/10/2015)

Ao contrário do que a Defesa insiste em tentar demonstrar, a situação que levou à prisão dos acusados não consistiu em ação ilegal da guarda municipal, tentando exercer funções próprias da polícia, uma vez que não se mostra presente a alegada exorbitância dos poderes que lhe são constitucionalmente atribuídos.

Nesse sentido:

"TRÁFICO. Nulidade da prisão efetuada por Guardas Municipais. Ausência de legitimidade dos Guardas Municipais para realização de busca pessoal. Ilicitude das provas colhidas. Prisão em flagrante que pode ser realizada por qualquer pessoa do povo - Art. 301 do CPP. Nulidade não reconhecida [...]" (TJSP; Apelação Criminal 1500200-65.2019.8.26.0551; Des. Relator: Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29.01.2020).

Não se tratou, portanto, de atuação ostensiva de guardas civis, extrapolando os limites da atribuição constitucional que lhes é conferida, tendo em vista a premência da situação de flagrante, como asseverado pela 16ª Câmara de direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em feito análogo desta Vara: "[...] Ressalte-se que as atribuições da Guarda Civil Municipal estão constitucionalmente previstas, não se confundindo com aquelas fixadas para os demais órgãos. De qualquer modo, todas integram o vasto campo da segurança pública a qual, conforme prevista pelo legislador constituinte, caracteriza-se "pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Mas, no caso particular dos guardas civis, o constituinte foi mais restrito, circunscrevendo a atuação à proteção dos bens, serviços e instalações do município, o que, obviamente, não inclui as ações próprias da Polícia Federal (art. 144, § 1º), da Polícia Civil dos Estados (art. 144, § 4º) ou mesmo da Militar (art. 144, § 5º). É, contudo, o mesmo texto constitucional que prevê a hipótese da prisão em flagrante como figura excepcional à exigência de prévia ordem judicial para a restrição da liberdade. A exceção, note-se, é justificada em face das circunstâncias extremas que cercam a situação flagrancial e que são representadas pelos requisitos da atualidade e imediatidade. Ou seja, naquelas hipóteses, o Estado está autorizado a recompor, prontamente, a ordem pública mediante a detenção urgente e temporária do suposto autor, até decisão judicial ulterior. Trata-se, repita-se, de providência urgente reveladora da supremacia que o valor segurança pública merece frente ao valor da liberdade, na hipótese de flagrante delito. Não são outras as razões que levaram o legislador infraconstitucional a impor o dever, às autoridades policiais e aos seus agentes, de efetuarem a prisão em flagrante, facultando-a a qualquer do povo. Assim, ainda que não seja possível subsumir-se a figura do guarda civil às hipóteses dadas pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, restar-lhe-ia o poder que é outorgado a qualquer do povo. Trata-se, note-se, de poder de graves consequências, o qual implica restrição da liberdade de locomoção. Logo, não soa razoável, para dizer o mínimo, estivessem todos investidos do poder de restrição de um dos mais importantes e valiosos direitos liberdade sem que tal fosse acompanhado de outros poderes implícitos, como é o caso da busca pessoal. Obviamente, tal conclusão há de ser tomada com ponderação, evitando-se uma ampliação indevida dos poderes restritivos dos direitos fundamentais. Não é o risco desenhado pelo caso dos autos. [...]" (TJSP; Apelação Criminal 1500279-53.2020.8.26.0569; Des. Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03.08.2022).

E a prova dos autos, como se verá adiante com mais detalhes, autorizava a abordagem inicial realizada pelos guardas municipais, e que depois, acabou por se tornar a apreensão de drogas realizada e que resultou na prisão de Juliana e Felipe.

Assim, rejeito as preliminares arguidas pela Defesa.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade dos crimes narrados na denúncia está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 25), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 05/08), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 16/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), laudos de exames químico- toxicológico (fls. 77/80 e 263/265), além dos elementos informativos e da prova oral, colhida

durante ambas as fases do feito.

A autoria também é certa, e recai sobre o acusado.

Em sede policial, Felipe se manteve silente sobre os fatos (fls. 21). Em juízo, Felipe disse que recebeu a droga naquele dia, guardou-a dentro de casa, e receberia R\$300,00 (trezentos reais), mas Juliana não sabia de nada. Contou que morava na casa há 04 meses, estava desempregado e aceitou receber essa mochila no mesmo dia em que foi preso, e era a primeira vez que recebia a mochila. Disse que Juliana já havia brigado com ele, para que parasse de usar drogas, e que a caixinha com 03 pinos era dele, para uso. Negou que teria arrendado uma biqueira no bairro. Disse que ficaria com a mochila apenas por uma noite, e iria receber o pagamento na mesma hora que devolvesse a mochila para o rapaz que iria pega-la. Afirmou: "eu nunca entregava a mochila na frente da minha casa" (sic), ao que foi reperguntado se ele já tinha entregue a mochila antes em lugar diverso, pois sua afirmativa pressupunha habitualidade. Disse que Juliana teria visto a mochila naquele mesmo dia, perguntou o que ela conteria, e ele teria respondido apenas, que iria devolver a mochila e que isso não iria prejudicá-la. Contou que já teve passagem por roubo em 2013, e que já ficou internado, devido ao uso de drogas, por um mês, em Porto Feliz, em 2020, pois já fez uso de maconha e de cocaína (fls. 247).

Antonio Alessandro Frois, guarda municipal, disse que estavam patrulhando a região, quando foram solicitados por um ciclista, que informou que o casal, morador do imóvel de número 488 da rua Itatiba, estaria mantendo e distribuindo drogas no bairro. Contou que se dirigiram à rua Araraquara e, no cruzamento, viram uma mulher andando com algo na mão esquerda e, ao vê-los, ela colocou o objeto dentro do bolso da blusa. Disse que a mencionada mulher era a ré que, ao ser questionada, retirou um celular e R\$7,00 (sete reais), informando morar na rua Itatiba nº 488, e foi avisada sobre a denúncia. Disse que a ré os conduziu até a casa, confirmando haver droga no local, onde, no quarto, havia uma mochila em cima da cama, contendo 350 frascos com lança-perfume, 94 microtubos de cocaína, 24 porções de cocaína, 38 microtubos de crack, 12 porções de maconha, 184 reais em dinheiro, 4 celulares e uma balança de precisão. Informou que a ré teria dito que mantinha a droga no imóvel há cerca de 3 meses, recebendo R\$300,00 por semana, para guardar e distribuir a droga no bairro. Relatou que, nesse momento, chegou o Felipe, que confessou o tráfico, dizendo ter arrendado um ponto de tráfico no Jardim Marília duas semanas antes, e que iria vender a droga naquele ponto. Relatou que ambos foram presos e encaminhados à Delegacia (fls. 246).

Regis Conceição, guarda municipal, prestou depoimento em perfeita consonância com o de seu colega de farda, acrescentando que o casal morava nos fundos da casa, que a casa de frente estava vazia e que ele não conhecia o casal de abordagens anteriores (fls. 246).

Maria Aparecida dos Santos, testemunha de Defesa, disse ser dona do imóvel em que os réus moram, e onde foram encontradas as drogas. Disse que não estava morando no local na época dos fatos, e os réus alugaram o imóvel por 4 meses, pagaram só a entrada e não pagaram mais. O réu teria dito que trabalhava numa cerâmica, e que a ré seria costureira e manicure (fls. 246).

Antonia Granjeiro de Oliveira, testemunha de defesa, disse que conhece a ré há cerca de 20 anos, pois trabalhou junto com a mãe dela, mas depois, ficou doente e não tiveram mais contato. Contou que a ré trabalhava ajudando a mãe, e que é muito fechada. Disse nada saber do relacionamento entre a ré e o réu, ou de quaisquer fatos que a desabonem (fls. 246).

Liliane Regina Silva da Rocha, testemunha de defesa, disse que conhece a ré há mais de 10 anos, e que ela é ótima pessoa, apesar de parecer ter algum problema, por ser um pouco avoada. Ao final, disse que não conhece o companheiro da ré e nem sabe seu nome (fls. 246).

Francisca Leneuda do Nascimento, testemunha de defesa, disse que conhece a ré desde 2004, foi vizinha dela e conhece sua mãe. Nada sabe que a desabone. Nunca soube que usasse ou vendesse drogas. Disse que a ré sempre foi trabalhadora, mas que mudou seu jeito depois de se juntar ao réu. Alegou ter presenciado uma briga deles, em que ela pedia para ele parar com as drogas (fls. 246).

Viviane Cristina da Silva, testemunha de defesa, confirmou sua declaração de fls.

155, onde havia dito que conhecia a ré, frequentava a casa da mãe dela, estavam sempre juntas em festinhas e reuniões familiares, que seria uma boa pessoa, alegre, trabalhadora. Na mesma declaração, havia mencionado que havia presenciado uma briga entre a Juliana e o Felipe, e que ela estaria descontente com o relacionamento (fls. 246).

Encerrada a instrução, restou cristalina a ocorrência dos crimes como mencionados na inicial acusatória.

A princípio, como já mencionado, a ré Juliana alterou expressivamente sua versão em juízo. Enquanto na Delegacia ela confessou o armazenamento das drogas e sua associação a Felipe com tal finalidade, buscou alterar tais fatos em juízo, ao negar tudo e atribuir responsabilidade exclusiva ao companheiro.

Restou evidente que Juliana, ao mudar todo seu discurso, tentava eximir-se da culpa e, ainda, beneficiar o próprio Felipe de eventual envolvimento à associação.

Ainda assim, a nova versão apresentada por ela e Felipe possuem pontos de incongruência como, por exemplo, o fato de Juliana dizer que moravam juntos há três meses, enquanto Felipe disse que moravam juntos há quatro meses. Sobre o "encontro da mochila com drogas", Juliana disse que havia acontecido semanas antes da prisão, e Felipe disse que ocorreu no mesmo dia da apreensão policial. Juliana também não conseguiu explicar a razão pela qual, se auto-intitulando contra o tráfico realizado (supostamente apenas) por Felipe, e estando ciente de que aquela mochila continha drogas, teria aceito sua permanência dentro de sua casa, especialmente dentro de seu próprio quarto. Obviamente, a justificativa de que não havia notado a mochila ali não convence, mormente porque o imóvel, de fundos, possui pouquíssimos cômodos e estes têm dimensões reduzidas, sendo todos eles limpos por ela, que os percorre, enquanto permanece em casa, não podendo deixar de perceber, em local tão pequeno, qualquer objeto estranho, notadamente, um grande, como uma mochila repleta de drogas, que certamente exalava odor muito estranho para uma pessoa (que se dizia) sem envolvimento com entorpecentes.

Por outro lado, os depoimentos dos mencionados agente públicos foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, e que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos

milicianos". (TJSP;Apelação Criminal1510160-57.2018.8.26.0526; Relator

(a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.

Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistiu qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado, até porque foi declarado que sequer conheciam o acusado ou sua companheira.

Ressalto que os policiais informaram que a mochila, contendo toda a droga, 03 radiocomunicadores e 01 balança de precisão, foi encontrada em cima da cama, diferentemente do quanto alegado pela companheira do acusado, que tentou dar a entender que estaria em local escondido ou de difícil acesso.

Portanto, as circunstâncias da ação, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, evidenciam a composse das drogas entre Juliana e Felipe.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173).

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

Deste modo, verifica-se que além de ser incontestado que Felipe realizava o tráfico de entorpecentes, já que ele mesmo confessou que guardava a droga destinada à venda, também restou comprovada e estreme de dúvidas a associação entre o réu e sua companheira, nos termos da fundamentação acima.

Ademais, patente a estabilidade da associação entre Felipe e Juliana, que perdurava há meses, e assim tenderia a continuar, não fosse a denúncia havida e a eficaz atuação dos guardas municipais a interromperem a empreitada criminosa que se protraía no tempo.

As funções de ambos eram idênticas e consistiam, ao menos, em realizar a guarda dos entorpecentes e petrechos, entregando-os aos demais indivíduos não identificados, tudo com a finalidade de cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, para posterior fornecimento e venda a terceiros.

Assim, pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, na forma mencionada na denúncia.

Por fim, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento dos crimes em testilha, que ocorreram até o dia 15 de fevereiro de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à sociedade que o réu praticou os crimes que lhe foram atribuídos na denúncia, sendo incurso nas penas do artigo 35, caput, e no artigo 33, caput, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, tudo c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, em momento incerto, mas anterior às 23h15min de 15 de fevereiro de 2022, na Rua Itatiba, nº 488, Jardim Marília I, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, associaram-se a um indivíduo ainda não identificado para a prática, reiterada ou não, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Também porque, na data de 15 de fevereiro de 2022, por volta de 23h15min, na rua Itatiba, nº 488, Jardim Marília I, nesta cidade e comarca de Salto-SP, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de desígnios com terceiro indivíduo ainda não identificado, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, adquiriram, tinham em depósito e guardavam, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 350 (trezentas e cinquenta) porções da substância popularmente conhecida como "lança-perfume", com massa bruta de 3,9kg (três quilos e novecentos gramas); 94 (noventa e quatro) porções de "cocaína", com massa bruta de 144,78g (cento e quarenta e quatro gramas e setenta e oito centigramas); 24 (vinte e quatro) porções de "cocaína", com massa bruta de 20,41g (vinte gramas e quarenta e um centigramas); 12 (doze) porções de "maconha", contendo a substância tetrahydrocannabinol (THC), com massa bruta de 30,04g (trinta gramas e quatro centigramas); e 38 (trinta e oito) porções de "cocaína", em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", com massa bruta de 25,12g (vinte e cinco gramas e doze centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, verifico a presença de circunstância que enseja a majoração das penas-bases do acusado nesta fase, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, bem como sua natureza, pontos estes que destoam do que comumente se apresenta em apreensões realizadas em feitos da mesma natureza na comarca.

Ademais, Felipe possui maus antecedentes, porquanto ostenta condenação transitada em julgado nos autos de nº 3001524-04.2013.8.26.0526, sendo certo que já transcorreu o prazo depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Assim, fixo suas penas-bases acima do mínimo legal, quais sejam, em 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e em 04 anos de reclusão e 800 dias-multa para o crime de associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Como acima mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública, razão pela qual aumento suas penas para: 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa para o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e para 04 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-multa para o crime do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ressalto que a atenuante da confissão espontânea não se caracterizou uma vez que o réu, malgrado tenha assumido que guardava a mochila naquela noite, tentou, sem sucesso e se contradizendo em seu depoimento, descaracterizar a habitualidade de suas ações. Além disso, buscou eximir sua companheira Juliana de qualquer envolvimento com os crimes, beneficiando-a e a si próprio.

Não há causas de aumento de pena e não é possível a aplicação do redutor no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a comprovada dedicação à atividade criminosa, enfatizada pela grande quantidade de drogas apreendidas em poder do réu e de sua companheira, além da condenação pela associação para o tráfico, crime que por si só já configura impeditivo à concessão do benefício pretendido.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, diante do concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 11 anos de reclusão, além de 1.500 dias-multa, que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras, fixando a unidade do dia-multa no mínimo previsto em lei.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu FELIPE DOS SANTOS PRADO, qualificado nos autos, RG 41.419.257, CPF 363.199.308-02, como incurso nas penas do artigo 35, caput, e no artigo 33, caput, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, tudo c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 11 anos de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 1.500 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, o acusado possui maus antecedentes, além de não preencher os requisitos legais para a concessão do benefício, porquanto condenado por crimes dolosos ao cumprimento de pena privativa de liberdade que supera os 04 anos (inciso I), além do que as circunstâncias do crime demonstram que a substituição por penas restritivas de direitos não se mostra suficiente, pois, além do cometimento de dois crimes equiparados a hediondos, o réu era parte de uma organização que praticava o tráfico de drogas com habitualidade, conduta de enorme repercussão em toda a sociedade (inciso III).

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade do delito praticado (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas também pelo montante de pena aplicado e, sobretudo, pela quantidade de droga apreendida, pelo potencial lesivo da conduta do réu que, com sua organização associada para a realização do tráfico de drogas, certamente, atingiria a milhares de usuários caso não tivesse havido a bem sucedida ação dos guardas municipais. Entendo, também, que neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção dos crimes praticados. Determino, ainda, que o réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, considerando que sua custódia foi determinada durante todo o decorrer do feito, permanecendo presentes os seus requisitos, já que se mostra inalterado o panorama do momento em que foi inicialmente determinada.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade,

circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Observe não ser caso de aplicação da ordem exarada nos autos do HC nº 165.704-DF, rel. Min. Gilmar Mendes, conforme deliberação na sessão virtual de 20 a 27 de agosto p.p., item "a", onde foi determinada "reavaliação das prisões preventiva de pais e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, de acordo com as diretrizes fixadas pela Segunda Turma", pois inexistem quaisquer elementos nos autos que comprovem que o réu se encontre na situação ali prevista.

Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).

Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/2006). Havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, ressalvada a necessidade de contraprova, nos termos da Lei.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 1º de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA